

1500542-39.2022.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO CONSTANTE DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADA COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500542-39.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500542-39.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124608/2022 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 24816335 -

DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2124608 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATA ALVES MARTINS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados Guilherme Mendonça da Silva e Jhonata Alves Martins, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso artigo 33, caput, em concurso material com o artigo 35, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, os acusados, no dia 07 de maio de 2022, às 11h, foram surpreendidos associados com o fim específico de praticarem, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas.

Ainda segundo a exordial, os acusados, no dia 07 de maio de 2022, às 11h, na Rua Francisco Saez Aiza, quadra 01, no bairro Habitacional Fortunado Rocha Lima, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, previamente associados e com unidade de desígnios,

foram surpreendidos com 549,18 gramas de maconha e 6,02 gramas de 'crack', para fins de tráfico.

Boletim de ocorrência (fls. 29/33), auto de exibição/apreensão (fls. 34/35), laudo de constatação preliminar (fls. 37/46) e laudo definitivo (fls. 262/267).

Pelo crime, foram os réus presos em flagrante.

Durante a audiência de custódia (fls. 61/62), foi o estado flagrancial convertido em prisão preventiva.

Pela decisão de fls. 117/118, foi recebida a denúncia e foi determinada a citação dos acusados.

Os réus foram formalmente citados (fls. 145 e 147), tendo ofertado respostas à acusação (fls. 153/163 e 182/183).

As decisões de fls. 168/178 e 188/189 e mantiveram o recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 228/230 foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e interrogados os réus.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 241/249 pugnando, em suma, pela procedência parcial da pretensão punitiva, condenando-se os acusados pelo delito de tráfico, nos termos da exordial, e absolvendo-os da infração penal de associação, em suma, pela ausência de estabilidade e permanência, com a valoração do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e a personalidade pernicioso no tocante ao réu Jhonata, reconhecendo-se a agravante do "estado pandêmico", e as atenuantes da confissão (Jhonata) e menoridade relativa (Guilherme), afastando-se o art. 33, §4º da Lei Antidrogas, com a fixação do regime inicial fechado, vedando-se eventual recurso em liberdade.

A D. Defesa do acusado Jhonata às fls. 233/237, pugnou pela ocorrência do "tráfico privilegiado", e pela absolvição quanto ao delito de associação, valorando-se a confissão espontânea, com a fixação do regime inicial aberto, substituindo-se a privativa por restritivas.

Já a C. Defesa do acusado Guilherme às fls. 252/261 pleiteou pela absolvição, no tocante a ambos os delitos, por falha no arcabouço probatório, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial aberto, a substituição da privativa por restritivas, com a possibilidade de eventual recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é parcialmente procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 29/33), auto de exibição/apreensão (fls. 34/35), laudo de constatação preliminar (fls. 37/46) e laudo definitivo (fls. 262/267).

A autoria, de outra banda, somente quanto à traficância, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

Os policiais militares Kennedy Aparecido Martins e Paschoal Fernando Alba, na fase judicial (mídia SAJ), em síntese, disseram que estavam, em patrulhamento pelo bairro Fortunado Rocha Lima, quando passaram pela Rua Francisco Saez Aiza, onde é comum a prática do tráfico de droga. Afirmaram que avistaram os acusados e, quando eles perceberam a presença da viatura, correram em direções opostas. Informaram que Jhonata foi detido pelo policial Kennedy, sendo que ele estava com uma bolsa com 18 porções de maconha embaladas em plástico transparente, além de um pote cilíndrico com algumas pedras de 'crack'. Esclareceram que o policial Paschoal abordou Guilherme após ele cair, sendo que ele estava na posse de uma mochila com 63 porções de maconha e a quantia de 127 reais em diversas notas e moedas. Mencionaram que eles confessaram o comércio de entorpecentes. Citaram que Jhonata disse que havia um barraco próximo dali onde eles 'picavam', 'fracionavam' e 'embalavam as drogas'. Asseveraram que foram até o barraco por eles indicado, onde havia mais porções de maconha, facas, uma balança de precisão e algumas embalagens usadas pela acondicionar as drogas.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda

pessoa poderá ser testemunha”.

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP. Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE

DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Guilherme Mendonça da Silva sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, negou a prática do crime. Disse que foi comprar droga do corréu Jhonata, que vendia maconha por cinco reais e 'crack', por cinco ou dez reais. Afirmou que, quando a polícia chegou, correu. Informou que Jhonata lhe contou, posteriormente, que 'trabalhava' naquele ponto das 07h até as 19h, e após tal período ele era substituído por outro traficante.

Já o acusado Jhonata Alves Martins sob o devido processo legal (mídia SAJ), e, resumo, confessou a prática delitiva. Disse que vendia a droga num barraco abandonado. Afirmou que, quando estava vendendo as drogas para Guilherme, a polícia chegou. Informou que 'falou para ele correr'. Esclareceu que comercializava a maconha por vinte ou cinco reais dependendo do tamanho e o crack por cinco ou dez reais. Mencionou que possuía 540g de maconha e 6g de crack para a venda. Citou que seu turno era das 07h às 19h. Asseverou que Guilherme iria pegar uma balinha de cinco reais. Disse que estava com as duas mochilas, mas quando correu, levou somente uma. Afirmou que as coisas que estavam num barraco lhe pertenciam. Informou que era usuário de maconha.

Pela prova colhida, é de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

O acusado Jhonata confessou o delito, na ocasião em que rememorou que vendia drogas, e ainda possuía petrechos em um imóvel (balança, plásticos transparentes e facas, fls. 34/35).

De outro lado, Jhonata citou que venderia drogas para Guilherme, o qual negou a traficância.

Com o acusado Guilherme foi apreendida mochila com 63 porções de maconha (montante incompatível com o consumo).

Aliás, na informação da vida pregressa de Guilherme, não foram apontados vícios (fls. 14).

Além disso, também é sintomático o comportamento de ambos.

Ora, ambos correram em direções opostas, sendo que Guilherme somente foi abordado 'ao cair e torcer o pé', quando, com ele, foi apreendida a quantia de R\$ 127,00, sem

lastro.

Importante citar, que segundo informações extraídas do mesmo “pregressamento” Guilherme estava desempregado.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 “caput” da Lei nº 11.343/06.

Diversamente, a associação para o tráfico não restou delineada.

Nada demonstra que havia estruturação, isto é, estabilidade, em muito, pela ausência de divisão de funções entre os acusados.

Ademais, também não restou comprovado que na pretensa associação haveria permanência, aqui entendida como o dolo (vontade) em continuar com a vinculação. Por isso, a absolvição, apenas quanto à associação é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO CONSTANTE DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADA COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Em relação aos pedidos de redução da pena-base e aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no crime de tráfico de drogas, com o consequente abrandamento do regime prisional, o presente recurso não merece conhecimento, pois o agravante não infirmou o fundamento constante da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ.

2. Quanto ao pleito absolutório, a Corte local, dentro do seu livre convencimento motivado, apontou elementos concretos que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico, sendo que o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes.

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 695777 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 19/10/2021)

Sob outro aspecto, os acusados devem permanecer encarcerados.

Da prova colhida, o local é conhecido ponto de tráfico.

Ademais, a variedade e natureza de parte da droga apreendida ('crack'), denotam que a ordem pública deve ser preservada.

No sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RELEVANTE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. GRAVE MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. Tem-se por devidamente fundamentada a prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada especialmente na relevante quantidade de droga arremessada ao presídio (545 gramas de maconha e 60 comprimidos coloridos de ecstasy), além de 87 gramas de maconha e 10 comprimidos coloridos de ecstasy apreendidos pessoalmente, o que justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Recurso em habeas corpus improvido.

(STJ, RHC 154193 / RS, RHC 154193 / RS, relator ministro Olindo Menezes, julgado em 26/10/2021)

Passo à fixação da pena.

Réu Guilherme Mendonça da Silva

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais (fls. 54).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Contudo, a natureza (crack) de parte da droga, denota que a pena deve ser exasperada em 1/5, perfazendo 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Aliás, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 preconiza que tais circunstâncias - quantidade e natureza - são preponderantes.

Tal conclusão é amparada pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. DESPROVIDO.

I - Conforme orientação do col. STF, a circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora na terceira fase da dosimetria, impedindo a aplicação ou modulando a fração de redução da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

III - No presente caso, afastou-se o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 348 (trezentos e quarenta e oito) pedras de crack, 2 (dois) cigarros de maconha, 18 (dezoito) pinos de cocaína e 2 (duas) porções de maconha, além da apreensão de 1 (uma) arma de fogo, calibre 380 e 35 (trinta e cinco) munições do mesmo calibre. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado.

IV - "[...] A questão discutida neste recurso especial não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal, tal como ocorre, por exemplo, com a valoração das circunstâncias judiciais (uma a uma). O caso, diversamente, demanda apenas o reexame da aplicação da pena, providência admitida em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou de equívoco evidente de fundamentação das circunstâncias judiciais (como no caso) ou, ainda, de erro de técnica no critério trifásico de aplicação da pena" (AgRg no REsp n. 1.475.447/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015). Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1753254 / MG, relator ministro Felix Fischer, julgado em 09/10/2018)

Na segunda fase, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)
Ainda na segunda fase, presente a “menoridade relativa”, o que atenua a reprimenda em 1/6, atingindo 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Na derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Com efeito, o tráfico era realizado em co-autoria.
Além disso, a quantidade de maconha extrapolou meio quilo.
Depois, foram apreendidos petrechos, que denotam que o acusado (com o corréu) se dedicavam a atividades criminosas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 500 G DE CRACK E 4,33 G DE COCAÍNA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. CONVICÇÃO ACERCA DA DEDICAÇÃO AO CRIME CALCADA NÃO APENAS NA QUANTIDADE DE DROGAS, MAS TAMBÉM NA APREENSÃO DE PETRECHOS LIGADOS AO FABRICO, EMBALO E COMÉRCIO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TESE DE QUE A DROGA NÃO PERTENCIA AO RÉU, MAS SIM AO CORRÉU. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 1208408 / SP, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E QUANTIDADE DE DROGAS . AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. QUANTUM DE 1/6 PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - Considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o pleito de reconhecimento da agravante da confissão espontânea, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

III - O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

IV - No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, quase meio quilo de maconha, bem como os maus antecedentes, para a exasperação da pena em 1/6, não havendo que se falar em desproporção, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 741807 / SP, relator ministro Jesuíno Rissato, julgado em 16/08/2022)

Por isso, a pena atingida na segunda fase é a definitiva.

Acusado Jhonata Alves Martins

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais (fls. 51).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Entretanto, a natureza (crack) de parte dos entorpecentes, denota que a pena deve

ser exasperada em 1/5, perfazendo 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa. Na segunda fase, como argumentado, inaplicável a agravante do “estado pandêmico”. Ainda na fase intermediária, presente a confissão (elemento utilizado como argumento de convicção), o que atenua a pena em 1/6, atingindo 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na final, inexistentes causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena intermediária é a definitiva.

Resta consignado, tal como motivado, que a quantidade e qualidade dos entorpecentes, impedem, como dito, o manejo da minorante do “tráfico-privilegiado”, em razão da ocorrência de atividade criminosa.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

Fixo o regime inicial fechado para ambos os acusados.

Com efeito, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 (nos termos do art. 33, §3º do Código Penal) não foi considerado inteiramente favorável.

Além disso, a droga era variada, e ao menos em parte perniciosa, o que denota que o regime mais gravoso é o único necessário e suficiente para a reprovação do crime.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade por suposta ausência de prévia suspeita à realização da abordagem policial – Inocorrência – Abordagem e revista pessoal realizadas após fundadas suspeitas, inexistindo qualquer ilegalidade no ato perpetrado pelos agentes estatais – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Condutas que se amoldam ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao artigo 129, parágrafo 12 e ao artigo 329, caput, ambos do Código Penal – Prova cabal a demonstrar que o acusado trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico, bem como que opôs-se a execução de ato legal e, ainda, que ofendeu a integridade física de um dos agentes estatais – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais, aliados ao laudo pericial químico-toxicológico definitivo e ao laudo de lesão corporal, possuem o condão de embasar o decreto condenatório – Concurso material de delitos devidamente configurado – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o sistema trifásico – Imperiosidade de fixação das reprimendas basilares acima de seus patamares mínimos legais, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do que dispõe o artigo 59 do Código Penal – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da evidência que o réu se dedicava à atividade criminosa, haja vista que possui apontamentos em sua folha de antecedentes e, inclusive, já foi condenado por ato infracional equiparado a tráfico de drogas, não obstante tal fato não gerar reincidência nos autos em comento – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito de tráfico – R. Sentença Reformada – Impossibilidade de fixação de regime fechado para delitos apenados com pena de detenção – Inviabilidade de aplicação do instituto da detração – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1500690-20.2021.8.26.0583, relator Des. Fátima Gomes, julgado em 24/10/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL, e deste modo:

ABSOLVO os acusados Jhonata Alves Martins e Guilherme Mendonça da Silva, qualificados nos autos, da infração penal prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII do CPP;

CONDENO os acusados Jhonata Alves Martins e Guilherme Mendonça da Silva, qualificados nos autos, a cumprir a pena, cada um deles, de 5 (cinco) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 “caput” da Lei nº 11.343/06.

Nego aos acusados o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados.

Considerando o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 34/35. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Quanto aos petrechos (balança, maço pequeno de pedaços de plásticos transparentes, facas) e entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeçam-se incontinenti guias definitivas de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os acusados a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA